

FUNDAMENTOS Y NORMATIVIDAD

EN CONTRATACIÓN PRIVADA Y ESTATAL



FAVA - Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje.

SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.

Estructura de contenidos

	Pág.
Introducción	3
Mapa de contenido	4
1. Generalidades sobre contratación.....	5
1.1 Tipos de contratos	5
2. Contratos privados	5
2.1 Código Civil: concepto de contrato, deberes y derechos	6
2.2 Derechos de autor	6
2.2.1 Programas de ordenador y base de datos	7
2.2.2 Derecho patrimonial y de derecho moral.....	8
2.2.3 Registro nacional de derechos de autor.....	9
2.2.4 Registro de software.....	10
2.3 Protección de datos.....	11
2.3.1 Ley 1266 de 2008 – Definiciones	12
2.3.2 Ley 1581 de 2012 – Definiciones	13
2.3.3 Decreto 1377 de 2013 – Definiciones	13
3. Contratos públicos.....	15
3.1 Ley 80 de 1993 (estatuto general de contratación de la administración pública)	15
3.1.1 Derechos y deberes de las entidades estatales.....	16
3.1.2 Capacidad para contratar	16
3.1.3 Principio de contratación estatal.....	17
3.1.4 Garantías que acompañan el contrato	18
Glosario	20
Bibliografía.....	22
Control del documento	23

Introducción

El presente material de estudio se estructura como una orientación de tipo legal para el aprendiz en formación, su contenido se presenta como referencia que puede ser tomada en cuenta al momento de elaborar un contrato de desarrollo de un sistema de información, indicando de acuerdo al tipo de contrato, cuáles son los aspectos legales más relevantes los cuales se describen según el tipo de contrato público o privado, se presentan las ideas principales y las referencias legales que la soportan, permitiendo establecer la relación entre cada uno de los aspectos de los contratos y el marco legal que le aplica.



Mapa de contenido



Desarrollo de contenidos

1. Generalidades sobre contratación

La elaboración de un contrato se determina por el tipo de contrato que se va a realizar y viene encausado en un marco de referencia legal acorde con las leyes en materia de contratación vigentes en Colombia.



1.1 Tipos de contratos

Existen varios tipos de contrato, pero lo que define su tratamiento legal es para qué tipo de cliente se va a realizar el desarrollo del sistema de información, por ejemplo, si se trata de una empresa privada o persona natural, o por el contrario si es a una organización estatal o ente público. Al definir esta característica del contrato, se establece la normatividad a tener en cuenta y que lo cubre.



2. Contratos privados

Para establecer qué tipo de contrato aplica, es importante responder la siguiente pregunta.



¿El sistema de información desarrollado se realiza para una organización o empresa del sector privado o para una entidad pública?

Si la respuesta a la pregunta anterior fue empresa privada con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro como las ONG, a continuación, se presentan los aspectos legales que se deben tener en cuenta. En el contrato al momento de realizarlo se debe establecer el objeto del contrato, derechos y obligaciones del contratista y el contratante. Todo esto está soportado en el Código Civil Colombiano.

Es importante tener en cuenta en la **contratación privada** los anteriores elementos para la elaboración del contrato, sus obligaciones, derechos y deberes se encuentran en el Código Civil que soporta el contrato como un acto civil, adicionalmente como el software o el desarrollo de sistemas de información debe estar protegido con derechos de autor la Decisión Andina, la Ley 23 de 1982 y sus modificaciones a través de los diferentes decretos establecen la protección de este tipo de obras. Por último, la información como elemento importante en la relación de cliente empresa o prestador del servicio. La protección de datos, los contratos y todo trabajo a realizar donde involucre tratamientos de los mismos debe incluir dentro de sus cláusulas elementos y herramientas enmarcados en la ley de protección de datos.

2.1 Código Civil: concepto de contrato, deberes y derechos

Todo contrato es un acuerdo entre dos o más individuos o empresas que se ponen de acuerdo en lo que se reconoce como el objeto del contrato, y de acuerdo al Código Civil se establecen a través de un documento unos derechos y unas obligaciones, y un objeto del contrato que en este caso será reconocido como una obra electrónica.



En el Código Civil se establece el término de estos derechos y obligaciones en su artículo 1495, que soportan el contrato, y el efecto de las obligaciones y obligaciones penales, así como su interpretación, validez y nulidad. Se define si es contrato de compraventa o contrato de arrendamiento, recordando que los sistemas de información se pueden arrendar como sistemas por servicios.



Una vez se ha establecido el objeto del contrato, los derechos y obligaciones a veces es necesario establecer cláusulas donde se especifican aspectos importantes del contrato como, por ejemplo, los derechos de autor.

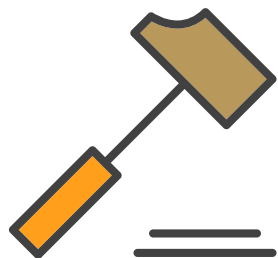
2.2 Derechos de autor

En esta sección del contenido se hace la aclaración de qué objeto está siendo cubierto por los derechos de autor. Para ello es necesario comprender lo que la Decisión Andina 351 describe sobre los derechos de autor y el tipo de obras sobre los cuales se ejerce este

derecho, teniendo en cuenta que en esa misma Decisión Andina se define el software como una obra literaria y como tal es susceptible de protección de derechos de autor.

La Decisión Andina 351 reconocida como el Acuerdo de Cartagena, establece el régimen común sobre derechos de autor para los países latinoamericanos.

En esta se establecen los principios de derechos de autor donde se protegen aquellas obras de ingenio sobre otras preexistentes, contando con previa autorización, tales como las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras. Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. La duración de la protección de los derechos reconocidos (morales y patrimoniales), no son inferiores a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. Cuando la titularidad de los derechos corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso.



2.2.1 Programas de ordenador y base de datos

En la Decisión Andina 351 los programas de ordenador se plantean como “Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador, un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.” El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. Frente a este aspecto se plantean las siguientes estipulaciones:



- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto. Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas.
- El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa siempre y cuando: sea indispensable para la utilización del programa y sea con fines de archivo,

es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida.

- La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.
- No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal. No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos.
- No constituye transformación, a los efectos previstos en el acuerdo 351, la adaptación de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilización.
- Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no se hará extensiva a los datos o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la conforman.

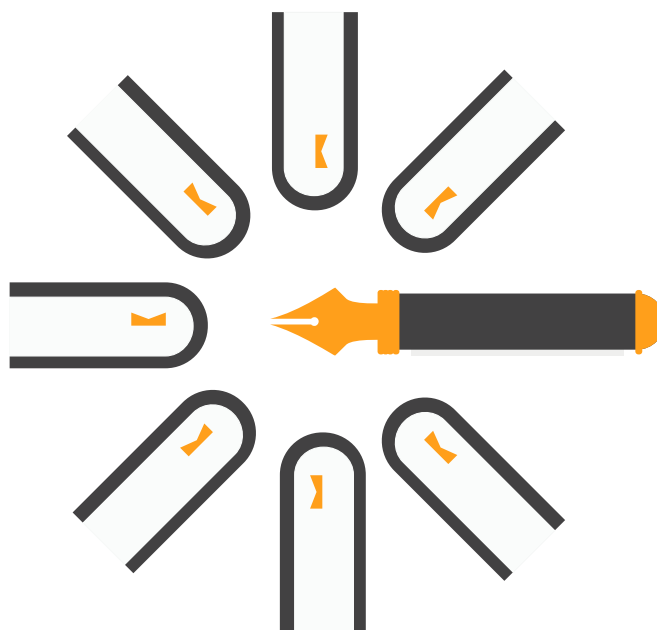
2.2.2 Derecho patrimonial y de derecho moral

De acuerdo a lo anterior la Decisión Andina establece la diferencia entre el derecho patrimonial y el derecho moral y sus limitaciones. El acuerdo 351 plantea que el **derecho moral del autor**, es decir la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra. Tiene el derecho inalienable, inembargable imprescriptible e irrenunciable de conservar la idea inédita o divulgar, reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento y oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.



Por otra parte, el **derecho patrimonial** se establece como: el autor o, en su caso, sus derechohabientes (persona natural o jurídica a quien por cualquier título se transmiten derechos reconocidos), tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir su reproducción total o parcial, la comunicación pública de la obra, la distribución pública, la importación, la traducción, adaptación arreglo u otra transformación de la obra.

Los derechos morales, son aquellos a los cuales el autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, e irrenunciable, es decir siempre existirán.



2.2.3 Registro nacional de derechos de autor

A nivel de Colombia la Ley 23 de 1982 establece a través de la reforma hecha a través de la Ley 44 de 1993 los tipos de obra que se pueden inscribir en el registro nacional de derechos de autor. Dentro de ellas se encuentran las obras literarias, los fonogramas, en virtud de los cuales se enajene el derecho de autor, así como cualquier otro acto o contrato vinculado con los derechos de autor o los derechos conexos.



También establece sanciones por la utilización indebida de esa propiedad intelectual por publicación, inscripción, reproducción total o parcial. Dentro de las sanciones más importantes está el de 1 a 4 años de cárcel y una multa de 3 a 10 salarios mínimos legales vigentes.

En el Decreto 1360 de 1989 en el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico del software en el Registro Nacional de Derechos de Autor. De acuerdo a ese decreto se abarcan los siguientes elementos a registrar:

- **Programa de computador:** la expresión de un conjunto organizado de instrucciones, en lenguaje natural o codificado, independientemente del medio en que se encuentre almacenado, cuyo fin es el de hacer que una máquina

capaz de procesar información, indique, realice u obtenga una función, una tarea o un resultado específico

- **Descripción de programa:** una presentación completa de procedimientos en forma idónea, lo suficientemente detallada para determinar un conjunto de instrucciones que constituya el programa de computador correspondiente.
- **Material auxiliar:** todo material, distinto de un programa de computador o de una descripción de programa, creado para facilitar su comprensión o ampliación como, por ejemplo, descripción de problemas e instrucciones para el usuario. El soporte lógico (software), es considerado como obra inédita (aquella que no haya sido dada a conocer al público) salvo manifestación en contrario hecha por el titular de los derechos de autor.

Para el registro se debe seguir el procedimiento que sugiere la Superintendencia de Industria y Comercio donde ellos llevan la gestión y el control del registro de derechos de autor en Colombia.

También se encuentran varios aspectos importantes en los decretos que la modifican como, por ejemplo, la transmisión de derechos de autor, el sistema de protección al derecho de autor, el software como producto patentable.

2.2.4 Registro de software

Para la inscripción del soporte lógico (Software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor, deberá diligenciarse una solicitud por escrito que contenga la siguiente información:



- Nombre, identificación y domicilio del solicitante, debiendo manifestar si habla en nombre propio o como representante de otro en cuyo caso deberá acompañar la prueba de su presentación.
- Nombre e identificación del autor o autores.
- Nombre del productor.
- Título de la obra, año de creación, país de origen, breve descripción de sus funciones y en general, cualquier otra característica que permita diferenciarla de otra obra de su misma naturaleza.
- Declaración acerca de si se trata de obra original o si por el contrario, es obra derivada.
- La declaración acerca de si la obra es individual, en colaboración, colectiva, anónima, seudónima o póstuma. (Estas obras se explican más adelante).

A la solicitud deberá acompañarse por lo menos de uno de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción de programa y/o el material auxiliar.



2.3 Protección de datos

Los contratos exigen algunos términos como el de la confidencialidad. Este punto es importante ya que la legislación obliga a proteger los datos de los clientes y los datos personales de todas las organizaciones y personas involucradas en un contrato.

La Constitución Política de Colombia, Artículo 15. Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012. Decretos Reglamentarios 1727 de 2009, 2952 de 2010 y 1377 de 2013 y las sentencias de la Corte Constitucional: C-1011 de 2008 y C-748 del 2011, reglamentan la protección de datos personales y de las empresas. En ellas recomiendan una serie de mecanismos que pueden ser aplicados al momento de establecer un contrato como por ejemplo la definición de una política de tratamiento de los datos.

Algunos puntos importantes de la Ley que hay que tener en cuenta sobre protección de datos, en especial las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, de las cuales se incluyen las utilizadas expresamente en estas Políticas, de la siguiente forma:



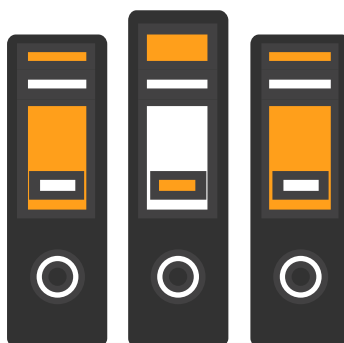
2.3.1 Ley 1266 de 2008 – Definiciones

- a. Dato Personal:** es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la Ley 1266 de 2008. Cuando en la Ley 1266 de 2008 se hace referencia a un dato, se presume que se trata de uso personal. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados. Para efectos de estas políticas, los datos personales definidos en la Ley 1266 de 2008 se denominarán “Dato personal crediticio”, en el entendido que incorporan la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, con el alcance dado por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-748 de 2011. En consecuencia, todo dato personal crediticio será exclusivamente cualquier información financiera o comercial destinada a calcular el nivel de riesgo crediticio del titular.
- b. Dato semiprivado:** es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la Ley 1266 de 2008.
- c. Dato privado:** es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular.
- d. Información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países:** para todos los efectos de la Ley 1266 de 2008, y de las políticas, se entenderá por información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen.



2.3.2 Ley 1581 de 2012 – Definiciones

- a. Dato Personal:** cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Para efectos de estas políticas, cuando se haga referencia al término “Datos personales”, se entenderá exclusivamente realizada a los datos personales definidos en la Ley 1581 de 2012, con el alcance otorgada por esta.
- b. Encargado del tratamiento:** persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.
- c. Responsable del tratamiento:** persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos.
- d. Tratamiento:** cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales (Ley 1581 de 2012), tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Para efectos de estas políticas se entenderá que el tratamiento abarca también la recolección, captura, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión de “Información protegida”, según se define este término en la sección III del presente documento.



2.3.3 Decreto 1377 de 2013 – Definiciones

- a. Datos sensibles:** se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de



- oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.
- b. Transferencia:** la transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable del tratamiento y/o el encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en la República de Colombia, envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera de la República de Colombia. Calle 73 #11-12, Bogotá, D.C. Colombia.
 - c. Transmisión:** tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado del tratamiento por cuenta del responsable del tratamiento. Las anteriores definiciones establecidas por las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 serán aplicables y tendrán el alcance que en cada norma se les otorga; en consecuencia, para efectos de su interpretación y aplicación dentro las políticas, es necesario tomar en consideración el sentido y ámbito específico de cada concepto dentro de la norma correspondiente. El Marco Normativo forma parte integral de las políticas, y en especial, las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, junto con el Decreto 1377 de 2013.



3. Contratos públicos

La contratación pública se determina cuando el contratante es una entidad de carácter público, es decir, para contratar con el Estado en Colombia existe normatividad específica que define todos los elementos, características y componentes necesarios de aplicar y cumplir a la hora de contratar con el estado.



3.1 Ley 80 de 1993 (estatuto general de contratación de la administración pública)

En el contrato al momento de realizarlo se debe establecer el objeto del contrato, derechos y obligaciones del contratista y el contratante. Al igual que en la contratación privada está soportado en el Código Civil Colombiano. Sin embargo, debido a que los dineros públicos son sagrados se establece la ley 80 de contratación de la administración pública, para todos los contratos públicos de empresas u organizaciones del estado.

En esta ley se establecen los estatutos de contratación con empresas u organizaciones estatales, se definen los derechos y deberes de las entidades estatales o públicas, los derechos y deberes de los contratistas, así como su capacidad para contratar donde se existe un procedimiento de verificación antes de firmar el contrato.



También se definen las inhabilidades y los procesos de resolución de conflictos en caso de incumplimiento por alguna de las partes y las garantías que el contratista debe ofrecer al momento de firmar el contrato.

Es importante reconocer la diferencia entre el contrato con entidades públicas comparado con el contrato de entidades privadas. Ambos se basan en el Código Civil de contratación, pero si es contrato es con entidades públicas, sobre esta aplica la ley 80 sobre el Código Civil.

3.1.1 Derechos y deberes de las entidades estatales

La Ley 80 plantea como derechos y deberes de los contratistas, que participan en la realización del proceso de contratación con la administración pública:



- a. Tienen derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.
- b. Colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.
- c. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren.
- d. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.
- e. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir acto o hecho. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato.
- f. Responder cuando se formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
- g. Responder por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.

3.1.2 Capacidad para contratar

Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deben acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se deben inscribir en la cámara de comercio de su jurisdicción.



- **Consorcio:** cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas en la propuesta y 14 del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y

omisiones que se presenten, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

- **Unión temporal:** cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

En los dos casos se debe designar una persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

3.1.3 Principio de contratación estatal

El proceso de contratación estatal se encuentra enfocado en garantizar la transparencia de la selección del mejor contratista. Este proceso de contratación se basa en tres modelos: sin formalidades plenas, directa y mediante licitación o concurso.



- **Contratación sin formalidades plenas:** contratar mediante la expedición de órdenes, las obras, trabajos, bienes o servicios, cuando su cuantía sea inferior conforme a los valores asignados según el presupuesto anual de la entidad.

Se entiende por formalidades plenas la elaboración de un documento escrito, firmado por las partes en el que además de establecer los elementos esenciales del contrato, se incluyen las demás cláusulas a que haya lugar. Las órdenes que se generen deben precisar al menos el objeto del contrato y la contraprestación.

- **Contratación directa:** la escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso. No obstante, el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, plantea que se puede realizar contratación directa cuando se declare una urgencia manifiesta, o cuando el valor del negocio esté comprendido dentro del límite legal de la menor cuantía.

La **urgencia manifiesta** existe cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos.

- **Contratación mediante licitación pública o concurso de méritos:** por la licitación se busca preservar la moralidad administrativa, a través de un procedimiento de selección objetiva que garantiza la transparencia e imparcialidad de los agentes estatales. El automatismo de la licitación asegura que el contrato le sea adjudicado al proponente que formuló la propuesta más favorable y elimina cualquier margen de favoritismo estatal en que la selección del contratista se funda en consideraciones de interés o afecto.

3.1.4 Garantías que acompañan el contrato

La Ley 80 plantea que el contratista debe prestar garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantiene vigente durante su vida y liquidación y a se ajusta a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado; este riesgo es aquel que corresponde a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, tales como, los de buen manejo y correcta inversión del anticipo o pago anticipado, cumplimiento del contrato, estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio, correcto funcionamiento de los equipos, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. En los contratos de obra y, en los demás que considere necesario la entidad, debe cubrir la responsabilidad civil frente a terceros, derivados de ejecución del contrato a través de un amparo autónomo contenido en póliza anexa.



(Escobar 1999) explica al detalle cada una de los riesgos que se manejan con el establecimiento de una póliza única de garantía:

- **Anticipo:** el objeto de esta garantía es proteger la integridad de la suma de dinero que generalmente se pactan en los contratos a título de anticipo, para facilitarle al contratista la financiación de los bienes, servicios u obras que constituyen el objeto de prestaciones a su cargo. La cuantía de esta garantía es del cien por ciento (100%) del valor que el contratista reciba a título de anticipo.
- **Cumplimiento del contrato:** esta garantía tiende a asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista, y en especial, las prestaciones principales a su cargo, tales como la ejecución a satisfacción de la obra, o la prestación del servicio, o la entrega de los bienes, dentro del plazo estipulado en el contrato. El valor del amparo de cumplimiento no puede ser inferior al monto de la cláusula penal ni al diez (10%) por ciento del valor del contrato. Esta garantía es exigible cuando ocurra cualquier hecho imputable al contratista (mora o retardo injustificado en la atención de sus compromisos, o por un incumplimiento definitivo de sus obligaciones); sin que se exima el derecho a la entidad estatal a declarar la cláusula de caducidad o la terminación unilateral.
- **Derechos laborales de los trabajadores:** si los contratistas no se allanan a satisfacer los derechos laborales de los trabajadores éstos podrán reclamar

directamente el pago a la entidad pública, la cual, se encuentra obligada solidariamente como beneficiaria de las obras o trabajos. En consecuencia, las garantías contractuales se extienden a cubrir el detrimento patrimonial que pueda sufrir la administración pública por el incumplimiento de la obligación del contratista de pagar a los trabajadores los derechos originados en el vínculo laboral. El valor de este amparo será igual cuando menos al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el término de vigencia del contrato y tres años más, que corresponde al período de tiempo que tienen los trabajadores para plantear sus pretensiones ante la jurisdicción laboral ordinaria.

- **Saneamiento por vicios ocultos (correcto funcionamiento y calidad del bien o servicio):** las obligaciones principales del contratista son básicamente dos:
 - La entrega a satisfacción de la obra, bienes o servicios y el saneamiento del objeto del contrato. La primera se satisface durante el plazo de ejecución del contrato, la segunda surge a partir de la terminación del contrato y su desconocimiento acarrea la responsabilidad poscontractual.
 - La garantía de calidad de los bienes o servicios protegen a la entidad pública, cuando se presentan vicios que no fueron oportunamente detectados al momento de la entrega de los bienes o trabajos, que revistan tal gravedad que la cosa vendida o la labor realizada no sirvan para el cumplimiento de los fines estatales, o que habiendo sido previstos por las partes al momento de la celebración del contrato, el valor comercial de las prestaciones habría sido considerablemente inferior al precio pactado. El término del amparo de estabilidad de la obra lo determina la entidad según la naturaleza del contrato y no será inferior a cinco (5) años.

Glosario

Acción: es el derecho de exigir alguna cosa y el modo legal que tenemos para pedir en justicia, lo que es nuestro o se nos debe por otro.

Acta: narración, relato de actos, audiencias, reuniones, etc.

Activo comercial: es todo cuanto posee un comerciante en dinero, muebles, créditos, bienes, raíces, títulos, rentas, etc.

Actor: es el que formula en juicio algún pedido o interpone alguna demanda.

Arras: señal (seña), dinero o cosa que se da cuando se constituye un contrato (especialmente el de compraventa).

Acción legitimada: requisito para presentar una causa de acción, en la que el demandante, además de la capacidad jurídica para demandar, tiene que demostrar un interés legítimo para hacerlo. En inglés significa, “standing”.

Contrato: medio a través del cual varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos.

Conciliación: consagrada en la ley 23/91, Decreto 265/91, Artículo 116 C.N., Ley 446/98 y Ley 640/00, es un conjunto de actividades a través de las cuales las personas envueltas en un conflicto, lo resuelven con la intervención de un tercero imparcial y facilitador llamado conciliador. Existen dos tipos de conciliación: en derecho y en equidad.

Consolidación: acción y efecto de reunir dos o más casos relacionados a los fines de atenderlos conjuntamente. La determinación de consolidar es judicial.

Contrato implícito: contrato en el que la promesa contraída por la parte promitente no es expresa, sino inferida de su conducta o de la ley.

Daños: en Derecho Penal, delito que implica la comisión de actos que lesionan la propiedad ajena. Comúnmente se conoce con el nombre de vandalismo.

Intervención: acción y efecto de intervenir o de solicitar permiso del tribunal para participar en un asunto, recurso o pleito.

Mediación: situación en la cual dos o más partes en conflicto aceptan la participación de un tercero como apoyo al proceso, quien no tiene poder de decisión, pero alienta a las partes a plantear alternativas de solución para así llegar a un acuerdo concertado.

Norma: precepto que debe ajustar las conductas, mediante las cuales se orientan los comportamientos sociales.

Nulidad: la nulidad de un acto es manifiesta cuando la ley expresamente lo ha declarado nulo, o le ha impuesto la pena de nulidad. Actos tales se reputan nulos aunque su nulidad no haya sido juzgada.

Permuta: el contrato de trueque o permutación tendrá lugar cuando uno de los contratantes se obligue a transferir a otro la propiedad de una cosa, con tal que éste le dé la propiedad de otra cosa.

Sentencia: en lo penal, es el pronunciamiento hecho por el tribunal en cuanto a la pena que se le impone al acusado. Aunque en principio no se aplica a otras determinaciones judiciales finales, como el archivo por fundamentos legales o después de un fallo absolutorio, en la práctica se está aplicando. Se distingue de fallo, que es el pronunciamiento que hace el tribunal por el que se condena o absuelve a un acusado. En lo civil, es el pronunciamiento hecho por el tribunal que pone fin a un pleito.

Seguro: es un contrato por el cual una de las partes se obliga, mediante cierta prima, a indemnizar a la otra de una pérdida o de un daño, o de la privación de un lucro esperado que podría sufrir por un acontecimiento incierto.

Tenencia: el que tiene efectivamente una cosa, pero reconociendo en otro la propiedad. Es simple tenedor de la cosa, y representante de la posesión del propietario, aunque la ocupación de la cosa repose sobre un derecho.

Bibliografía

Cárdenas, G. (2006). *Guía para la elaboración de contratos*. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.

Código Civil Colombiano (2017). Recuperado de https://oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Colombia.pdf

Constitución Política de Colombia (2017). Recuperado de <http://www.constitucioncolombia.com/>

Decisión andina 351 de 1993. *Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos*. Recuperado de <http://derechodeautor.gov.co/decision-andina>

Ley 23 de 1982. *Sobre derechos de autor*. Recuperado de <https://goo.gl/EY4Y4i>

Ley 80 de 1993. *Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*. Recuperado de <https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/decreto-1170-2015/Ley-80-de-1993.pdf>

Ley 1581 de 2012: *Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Recuperado de https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4274_documento.pdf

Control del documento

CONSTRUCCIÓN
OBJETO DE
APRENDIZAJEFUNDAMENTOS Y NORMATIVIDAD EN
CONTRATACIÓN PRIVADA Y ESTATALCentro Industrial de Mantenimiento Integral - CIMI
Regional Santander**Líder línea de producción:** Santiago Lozada Garcés**Asesores pedagógicos:** Rosa Elvia Quintero Guasca
Claudia Milena Hernández Naranjo**Líder expertos temáticos:** Rita Rubiela Rincón Badillo**Experto temático:** Edward José Beltrán Lozano**Diseño multimedia:** Eulises Orduz Amezcuita**Programador:** Francisco José Lizcano Reyes**Producción de audio:** Víctor Hugo Tabares Carreñocreative
commons

Este material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de la licencia que el trabajo original.